

1500675-28.2022.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... de envolvimento de Rodolfo com tráfico de cocaína. Não tem conhecimento de envolvimento de Rodolfo com o maior traficante da região. Não tem conhecimento de envolvimento de Rodolfo envolvido com pessoas envolvidas em tráfico. Não tem conhecimento de movimentação de dinheiro envolvendo Rodolfo, tampouco de grandes quantias.

A testemunha José Da Dalto, policial civil, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500675-28.2022.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500675-28.2022.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054041/2022 - DEL.POL.BARIRI, 23235603 - DEL.POL.BARIRI, 262/22/202 - DEL.POL.BARIRI, 2054041 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

RODOLFO HENRIQUE DEMÉTRIO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 8hs00min, na rua Geraldo Barbieri, 48, centro, nesta cidade e comarca de Bariri, RODOLFO HENRIQUE DEMÉTRIO, guardava, para fins de tráfico de drogas, 02 (dois) frascos lacrados e 03 (três) abertos, contendo as substâncias Isocaproato de Testosterona (sustanon) 250mg/ml e drostanolone propionate, consideradas drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa prévia às fls. 225/284.

Às fls. 516/519, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 600/611, requerendo a condenação nos termos da denúncia, tecendo considerações sobre a fixação da pena-base e requerendo a fixação de regime fechado.

A Defesa, por sua vez, nas alegações finais de fls. 623/742, alegou a nulidades das interceptações telefônicas e telemáticas deferidas no processo nº. 1500596-

83.2021.8.26.0062, com a consequente declaração de ilegalidade e desentranhamento das provas, declarando-se nulo o processo desde o início; subsidiariamente, pugnou pela absolvição, conforme art. 386, VII, do CPP; ainda subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da LD, ou, não sendo o caso, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINAR

De plano, de rigor a análise da alegação de nulidade das interceptações deferidas nos autos de nº 1500596-83.2021.8.26.0062, mediante as quais foram amealhados os elementos de informação que formaram a opinião delicti do Ministério Público e impuseram a deflagração da presente ação penal.

As alegações defensivas, no aspecto, não prosperam.

Naqueles autos, após Representação para interceptação telefônica, formulada pela Autoridade Policial da Polícia Civil desta Comarca, com manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida a medida cautelar de interceptação telefônica do ora réu, bem como a autorização para interceptação de mensagens de texto, e-mails e extratos diários de ligações efetuadas e recebidas pelo mencionado telefone, com base nos fundamentos expostos na decisão de fls. 15/24 dos autos de nº 1500596-83.2021.8.26.0062, em apenso.

O deferimento da medida cautelar obedeceu aos requisitos previstos na Lei 9.296/1996, porquanto calcado em indícios de autoria (*fumus comissi delicti*) baseados em investigação prévia realizada pelo órgão policial, que trouxe ao Juízo relatório de investigação geral, contendo informações sobre a suposta atuação espúria do réu, no âmbito da Lei 11.343/2006.

Indispensável consignar que, ao contrário do alegado, o deferimento da interceptação não esteve calcado, exclusivamente, em denúncias anônimas, como se consignou na decisão. Na realidade, como se consignou na decisão, após o recebimento de tais notícias inqualificadas, os policiais realizaram outras diligências preliminares, as quais resultaram infrutíferas e impuseram a decretação da medida excepcional. Nesse sentido, veja-se excerto da fundamentação: "Segundo, porque os indícios de autoria (*fumus comissi delicti*) estão suficientemente demonstrados. Com efeito, o relatório nº 229/2021, aponta a obtenção de informações, pelo Setor de Investigações Gerais - SIG, de que o representado estaria 'atuando no comércio de drogas, dando prioridade para a venda de COCAÍNA, dominando grande parte do tráfico na cidade de Bariri - SP e região, bem como agindo no fornecimento de armas de fogo'. Consignou-se, ainda, que o representado 'ostenta carros e motos de valores altíssimos'. Vale salientar que, conforme relatório elaborado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, de nº 202107310612943, policiais militares receberam denúncias anônimas de que, por volta das 17h, haveria uma transação de drogas no local ali especificado (próximo à uma usina), a envolver 'um tal de Rodolfo', que estaria conduzindo uma moto de grande porte. Nesse caminho, segundo consta, os policiais intensificaram o patrulhamento nas proximidades do local, e, em dado momento, houve encontro da viatura com moto com as mesmas características informadas, a qual, desobedecendo sinal de parada, imediatamente retornou na via. Consta ainda que, seguindo os policiais no encalço,

o condutor da motocicleta ignorou as ordens de parada e passou em alta velocidade, havendo o reconhecimento, pelos policiais, de que o condutor se tratava do ora representado. Ademais, foi relatado, ainda, que inclusive foi deslocado helicóptero para a localização, sem sucesso; e, posteriormente, em pesquisas pela placa, verificaram que o proprietário do veículo FTE 7H51 era o representado. Como percebo, diante de denúncias anônimas, a polícia realizou diligências preliminares, as quais, todavia, resultaram infrutíferas, de modo que o conjunto desses elementos de informação traz suficientes indícios de autoria, a autorizar a interceptação pretendida.” (sublinhei).

Assim, não há que se falar em “fabricação” de indícios pelos órgãos policiais, o que não se confunde com a prestação de informações que, ao cabo da investigação, mostraram-se irrelevantes (como a forma de obtenção de patrimônio), sobretudo porque o deferimento da medida cautelar probatória não esteve calcado exclusivamente nessas informações, mas, especialmente, nas diligências prévias infrutíferas, indicadas na decisão impugnada.

O fato de a interceptação telefônica ter revelado, como adiante se verá, comercialização de drogas ilícitas distintas daquelas que constavam no relatório de investigação policial (anabolizantes e esteroides, e não cocaína), em nada invalida a medida cautelar, - até porque não se exige dos órgãos de investigação que tenham conhecimento integral e em profundidade do delito investigado, antes de requerer a cautelar probatória - caso contrário, sequer ela seria necessária. O que a Lei 9.296 exige são indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, com clara descrição da situação objeto da investigação, a envolver fato que constitua infração penal punida com reclusão, com prova que não possa ser feita por outros meios, requisitos todos plenamente atendidos no caso em tela.

O fato de a testemunha Rafael Bettini (em depoimento transcrito no próximo item) ter declarado desconhecimento sobre envolvimento do réu em traficância é irrelevante, pois ela própria afirmou que não participou da elaboração do relatório investigativo. Por outro lado, a testemunha José Da Dalto, em juízo, confirmou o compartilhamento de informações com a Polícia Militar, reforçando as diligências que foram feitas pelos órgãos policiais e que instruíram o pedido de interceptação. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Demais disso, há que se observar que, no decorrer da interceptação, a descoberta fortuita de elementos relacionados à materialidade da infração penal objeto desta denúncia caracterizou típico caso de serendipidade, não havendo que se falar em nulidade.

Nessa quadra, não se olvida que, eventualmente, a execução da cautelar probatória pode trazer à tona elementos até então desconhecidos e cuja descoberta se dá de forma ocasional como resultado do avanço das investigações. Trata-se do chamado encontro fortuito de provas ou serendipidade. A esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal é pacífica ao apregoar que a serendipidade é fato legítimo, consubstanciado na descoberta, por meio da interceptação telefônica, de infração penal (serendipidade objetiva) ou do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas (serendipidade subjetiva), não havendo que se falar em ilicitude probatória na descoberta de tais elementos, até porque não houve desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.

A comprovar o exposto:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE INVESTIGAÇÃO DIVERSA. OPERAÇÃO MERCADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-

se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 2. No caso, conforme se extrai da exordial acusatória, o crime de evasão de divisas foi descoberto fortuitamente por meio de interceptação telefônica, decorrente de investigação diversa, no contexto da Operação Mercador, em que se apuravam crimes de contrabando e descaminho de produtos em tese praticados pelos mesmos acusados. 3. Em homenagem à perfeita aplicação da serendipidade, entende-se que as provas são lícitas, sobretudo porque originadas de interceptação telefônica em desfavor da mesma ré. (...) 5. Recurso não provido.” (STJ, RHC n. 94.803/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 9.296/96. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. Os elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade. Precedentes: HC 129.678, Primeira Turma, relator p/ acórdão, min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/2017; HC 106.152, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 167550 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, publicado 03/09/2019)

Diante do exposto, reconheço a higidez das interceptações telefônicas e quebra de dados telemáticos, e, por via de consequência, afasto a preliminar suscitada. Quanto ao mais, o feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A existência do fato foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrência de fls. 15/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls.19/20; laudos de fls.32 e fls. 525/529; e, ainda, pela prova coligida em Juízo. Com relação à autoria, o réu, em seu interrogatório, declarou que Roger lhe pediu anabolizantes. É usuário de anabolizantes há muito tempo. “Ele me ligou depois de um tempo, pediu se eu tinha para oferecer para ele. Eu falei que tinha. (...) Mas depois ele não veio atrás de mim, porque ele nem mora mais na cidade”. Usa esse tipo de substância há uns dez anos, entre “idas e vindas”. É proprietário e professor em uma Academia, tem formação como educador físico. As pessoas de seu convívio tinham conhecimento de que é usuário dessas substâncias. Fazia acompanhamento com um médico esportivo, ele lhe mandava comprar os anabolizantes na internet, e então os adquiria. Um tempo atrás, uma pessoa de uma loja de suplementos passou a vender. Sempre comprava sem receita médica. Todavia, em que pese a negativa de autoria, o conjunto probatório dos autos demonstra, com suficiência, a autoria delitiva. Consoante relatório de fls. 48/72, elaborado a partir da interceptação telefônica, o réu, no dia 24/09/2021, comercializou a pessoa identificada como “Roger” drogas ilícitas (anabolizantes), valendo transcrever o seguinte excerto do diálogo

captado:

Veja-se que o réu afirma que possui testosterona, fixa o preço da transação e, inclusive, presta orientações a respeito de como utilizar a substância, afirmando que toda segunda-feira a entregará ao interlocutor.

Os diálogos interceptados são elucidativos e robustos quanto à autoria delitiva, valendo salientar que, quanto aos dados telemáticos, foram obtidas inclusive fotografias armazenadas pelo réu, relacionadas aos anabolizantes que comercializava (fls. 64, 65, 66, 68, 69).

Note-se que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, realizado na residência do réu, foi então encontrado o objeto material do delito, consistente em Isocaproato de Testosterona (sustanon) 250mg/ml e Drostanolone propionate (auto de exibição de fls. 19/20), substâncias ilícitas (visto que não possuem registro na Anvisa). Além disso, foram apreendidas seringas e agulhas, próprias ao manuseio das substâncias.

Com relação à prova oral, a testemunha Rafael Bettini de Oliveira, policial civil, declarou que “ajudou” no cumprimento do mandado de busca e apreensão, na academia do réu. Posteriormente, foi à casa de Rodolfo, onde foram localizados dois frascos de anabolizantes e outros três que estavam vazios. Foram localizadas seringas e agulhas, mas não sabe mencionar a quantidade. Não chegou a conversar com Rodolfo no dia do local. Só foi dar apoio ao cumprimento do mandado de busca. Tem conhecimento da interceptação telefônica e da quebra de dados telemáticos. Não participou de relatórios, ajudou na quebra telemática. Não tem conhecimento do tipo de atividade que Rodolfo desenvolvia. Na academia, nada de ilícito foi encontrado. Não tem conhecimento de envolvimento de Rodolfo com tráfico de cocaína. Não tem conhecimento de envolvimento de Rodolfo com o maior traficante da região. Não tem conhecimento de envolvimento de Rodolfo envolvido com pessoas envolvidas em tráfico. Não tem conhecimento de movimentação de dinheiro envolvendo Rodolfo, tampouco de grandes quantias.

A testemunha José Da Dalto, policial civil, declarou que, inicialmente, nos trabalhos de investigação, a Polícia recebeu diversas informações, entrelaçadas também com informações da Polícia Militar, envolvendo o réu. Fizeram o relatório e o Delegado solicitou interceptação telefônica; nas diligências, havia dificuldade de abordá-lo, tendo o réu empreendido fuga em diversas ocasiões em que a Polícia Militar tentava abordá-lo. Havia suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Em interceptação, em conversa com pessoa chamada Roger, verificaram comercialização de anabolizantes. Havia imagens de armas de fogo de diversos calibres e tipos. Existia um laço de Rodolfo com outras pessoas, mencionadas nominalmente, e então fizeram os trabalhos de busca. Na residência, localizaram anabolizantes e agulhas, seringas, munições, que acabaram não sendo apreendidas porque ele apresentou documentos. Na residência dos demais citados, não tiveram êxito em encontrar as armas de fogo. Na Academia, nada foi localizado. A equipe que fez a busca na Academia o acompanhou; depois, Rodolfo compareceu à residência. A esposa franqueou a entrada, posteriormente, lá compareceram Rodolfo e seu defensor. Rodolfo disse que faz uso dos anabolizantes, e não apresentou prescrição médica. As informações tratavam sobre tráfico de cocaína e de armas, e da união dele com Zeca Araújo, pessoa que não é de Bariri, e há informações de que ele estava comercializando armas. Rodolfo sempre fugia da polícia militar. Na casa de Vagner, localizaram armas, mas eram legalizadas. Acompanhou a quebra do sigilo telemático. O telefone de Rodolfo não pôde ser averiguado, pois o réu não forneceu a senha e a Polícia Científica não conseguiu quebrá-la. Rodolfo demonstrava conhecimento sobre a aplicação dos anabolizantes. A Polícia Militar relatou ter empreendido diligências para fazer a abordagem de uma moto grande, mas não conseguiu. Sabe que a moto é de Rodolfo.

A testemunha de Defesa, Cláudia Deolinda de Oliveira Martins, declarou ter

conhecimento sobre herança recebida pelo réu. Tem conhecimento de que Andréia, mãe de Rodolfo, o ajudava Rodolfo, seu "filho do coração". Andréia montou academia para ele, "deu uma moto boa", "construiu bastante coisa para ele", isso é o que ouviu falar. Não tem conhecimento e nunca ouviu falar que Rodolfo estivesse envolvido em tráfico.

A testemunha de Defesa, Ivo Orlando Berbel Filho, declarou que fez uma venda de uma motocicleta com Rodolfo. A data, exatamente, não se lembra. Era uma moto BMW, no valor de R\$ 37.000,00. Recebeu um cheque de Rodolfo, no valor de R\$ 37.000,00, o cheque não era dele – era da mãe dele. Mora em Bariri há 55 anos. Tinha a moto há "dois anos e pouco". Conhece o investigador "Da Dalto". Ele nunca entrou em contato com a testemunha, Ivo, para ter conhecimento sobre a origem da moto. Não tinha conhecimento de que Rodolfo estivesse envolvido em tráfico de cocaína.

Como percebo, as testemunhas de defesa foram meramente abonatórias com relação à forma de aquisição do patrimônio do réu, o que se mostra irrelevante para análise da autoria, amplamente demonstrada pelas demais provas dos autos.

Por outro lado, o conjunto probatório amealhado, notadamente diálogos interceptados e resultado do cumprimento do mandado de busca e apreensão, comprovam com robustez a autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Da mesma forma, descabida a tese defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da LD.

A esse respeito, relembre-se o art. 28, §2º, da LD, in verbis: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso dos autos, os diálogos interceptados não deixam dúvidas de que o réu guardava, para fins de tráfico de drogas, 02 (dois) frascos lacrados e 03 (três) abertos, contendo as substâncias Isocaproato de Testosterona (sustanon) 250mg/ml e drostanolone propionate, tanto é assim que o comercializava a terceiros, fixando-lhe o preço e condições de entrega.

Outrossim, a condição de usuário não ilide necessariamente a de traficante e, não raras vezes, confunde-se no mesmo indivíduo, que faz do comércio ilícito a forma de sustentar o próprio vício.

Ademais, é firme o entendimento de que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, bastando, para a incursão no crime de tráfico, que o agente incorra em qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, como ocorreu no caso. Portanto, não cogito a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. A corroborar o exposto, em situações semelhantes: "A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício." (TJSP.

Acórdão 1306853, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Logo, analisando o conjunto probatório, vê-se que, embora o réu alegue que os entorpecentes se destinavam, exclusivamente, a seu consumo pessoal, a tese defensiva não comporta acolhimento.

A autoria foi comprovada de forma segura e robusta, não se cogitando de insuficiência probatória.

Note-se que, inclusive, foram apreendidas a quantidade expressiva de 30 agulhas e 11 seringas (fls. 19/20), de modo usual ao comércio, a denotar a finalidade de entrega de terceiros, e não a exclusivo consumo pessoal.

Assim, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que o réu, de fato, guardava, para fins de tráfico, as substâncias apreendidas, e foi preso em situação de flagrante (art. 302 do CPP), não se cogitando de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Portanto, presentes a materialidade e a prova segura da autoria, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade penal.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o

dispositivo prevê: “§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

Nessa toada, consoante definido pelo STF, 2ª Turma, no HC 154.694/SP, para fins do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, milita em favor do réu a presunção de que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público, do qual se desincumbiu a contento no caso em tela.

Embora o réu seja primário (fls. 81/82), os diálogos interceptados demonstram rotineira incursão criminosa, pois promete a seu interlocutor que toda segunda-feira lhe entregará a substância ilícita, para reposição (fls. 51).

Além disso, a análise dos diálogos revela grande expertise na ministrarção das substâncias ilícitas (fls. 51), a demonstrar que não se tratava de réu a, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Desse modo, tem-se que as substâncias que guardava em sua residência não eram destinadas à comercialização meramente eventual, mas, sim, a uma atividade que se prolongava no tempo. Inviável, pois, falar-se em tráfico eventual e ausência de dedicação à atividade ilícita, motivo pelo qual afasto a benesse do art. 33, §4º, da LD.

Ante o exposto, suficientemente comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, é peremptória a responsabilização penal do réu.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do caso em tela, não é o caso aplicar a sanção-base acima do mínimo legal.

Consoante entendimento do TJSP, “(...) a natureza da substância (cocaína), por si, não impõe, necessária e automaticamente, o aumento da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.”

(TJSP; Apelação Criminal 1501716-98.2019.8.26.0526; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021).

Assim, e tendo em vista que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos (STJ, HC Nº 567.261 – RJ, - DJe: 16/06/2020), a quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso destes autos, não justificam o aumento da pena.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

O réu não possui maus antecedentes.

Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo, ausentes atenuantes ou agravantes.
Logo, estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição.

Portanto, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Regime inicial

Para a fixação do regime inicial, cumpre observar os critérios do art. 33, §§2º e 3º e art. 59, todos do Código Penal.

No caso dos autos, o réu é primário e não há adequação na fixação de regime inicial mais gravoso, mormente ante o quantum da pena.

Estabeleço, pois, o regime inicial SEMIABERTO, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal) neste momento, porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Diante do quantum da pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RODOLFO HENRIQUE DEMETRIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO; e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

"Status Libertatis": não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, inalterada a situação fática que embasou a concessão de liberdade provisória. Logo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

a) intime-se o réu para pagamento da multa;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Como os celulares apreendidos estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva – objetos para sua prática –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP). Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos que sejam inservíveis. Com o trânsito em julgado, oficie-se (Lei 11.343/06, artigo 63, § 1º).

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA